

1106126-24.2018.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Franquia

Magistrado: Eduardo Palma Pellegrinelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit - grifado).

Desta forma, os contratos são inevitavelmente válidos, salientando que não foi apontada eventual motivo concreto para justificar conclusão contrária.

No mais, em relação à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1106126-24.2018.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1106126-24.2018.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Franquia

Requerente:

House Maid Profissionais de Limpezas Domésticas Ltda.

Requerido:

VP Limpeza Profissional Ltda.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Palma Pellegrinelli

Vistos.

1. Relatório

Trata-se de ação promovida por HOUSE MAID PROFISSIONAIS DE LIMPEZAS DOMÉSTICAS LTDA em face de VP LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA, visando a rescisão do contrato de franquia por culpa da franqueada, com a condenação desta ao pagamento de multas rescisórias, de débitos a título de royalties, taxa de uso de sistema de informação e fundo de marketing, e ao cumprimento de obrigação de não-concorrência, com a determinação de encerramento das atividades das duas unidades franqueadas (fls. 01/38), na qual a ré-reconvinte propôs reconvenção visando a anulação do contrato de franquia ou, sucessivamente, a sua rescisão por culpa da franqueadora, com a condenação desta ao ressarcimento de valores e a indenização por danos materiais (fls. 614/652).

Alega a autora-reconvinda, em síntese, que, em 27/07/2015, as partes pactuaram contrato de franquia para operação de unidade da rede de prestação de serviços de limpeza doméstica "House Maid", localizada no bairro da Vila Romana; que em 01/04/2017 pactuaram segundo contrato de franquia em razão da aquisição, pelas rés-

reconvintes, da unidade "House Maid" situada no bairro de Perdizes. Entretanto, em 21/08/2018, a ré-reconvinte teria promovido a denúncia antecipada do contrato, alegando o descumprimento de deveres legais e de obrigações contratuais da franqueadora. Nesse sentido, alega a autora-reconvinda que adimpliu com todas as suas obrigações contratuais quanto à prestação de serviços de suporte, assistência operacional, treinamento, manutenção de padrões de qualidade, desenvolvimento de planos de publicidade, e acesso a sistema de gestão informatizado; que cumpriu seus deveres legais quanto à apresentação da Circular de Oferta de Franquia à ré-reconvinte; que, ainda que não tivesse cumprido com o dever de entrega da COF, o contrato estaria convalidado pelo decurso do tempo (3 anos e 4 meses); e que inexistiria abusividade nas cláusulas de obrigações das partes incluídas nos contratos de franquia. Alega, ainda, que, dois meses antes do pedido de rescisão, a ré teria criado domínio próprio www.ellaaajuda.com.br, também voltado à prestação de serviços domésticos; e que teria passado a divulgar suas atividades como uma startup independente, se apropriando indevidamente do know-how obtido em razão do contrato de franquia e gerando confusão aos clientes da marca da autora-reconvinda; que "alterou de forma premeditada, todos os dados de cadastro dos clientes da 'House Maid', incluindo telefones de contato e e-mail que não existem e substituindo os originais e verdadeiros, por estes registros falsos", sendo que de 558 clientes registrados só teria sido possível a recuperação de dados de 16; e que teria inadimplido com taxas de royalties, serviço de informática e fundo de marketing. Em vista disso, postula a condenação da ré-reconvinte ao pagamento dos débitos e das multas contratualmente previstas, bem como ao cumprimento da obrigação de não-concorrência.

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 39/594).

Houve a citação (fls. 613).

Por ocasião da resposta com reconvenção foi alegada, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade ativa. No mérito, foi alegado, em síntese: que haveria "nulidade" do negócio porque a autora-reconvinda não estaria autorizada pelos titulares da marca em Portugal a realizar sua exploração no Brasil; que a autora-reconvinda não teria cumprido o dever legal de entregar a Circular de Oferta de Franquia antes que o negócio fosse pactuado entre as partes; e que houve o inadimplemento das obrigações da autora-reconvinda no âmbito dos contratos de franquia, ensejando o pedido de rescisão dos contratos. Nesse sentido, foi alegado que a autora-reconvinda teria descumprido suas obrigações quanto a prestação de serviços de suporte, assistência operacional, marketing, treinamentos, aquisição de produtos e uniformes, manutenção de padrões de qualidade, desenvolvimento de planos de publicidade, e acesso a sistema de gestão informatizado; que o contrato "é leonino, pois sequer possui cláusulas de obrigações da franqueadora"; que não houve premeditação quanto à rescisão do contrato e inexistiria irregularidade quanto à manutenção de suas atividades com metodologia própria. Foi alegado, ademais, que inexistiriam débitos em aberto; que seriam inaplicáveis as multas contratuais postuladas pela autora-reconvinda, bem como a obrigação de não-concorrência; e que seria devida a condenação da autora-reconvinda ao ressarcimento de valores e ao pagamento de indenização por perdas e danos (fls. 614/652).

A contestação foi instruída com documentos (fls. 653/1.150).

Por ocasião da resposta à reconvenção e da réplica à contestação da ação (fls. 1.157/1.258), foi alegada, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa. No mérito, foi alegado que a franquia estaria regularmente autorizada pelos titulares da marca "House Maid" em Portugal, que teria sido objeto de contrato de cessão; e, no mais, foram reiteradas as alegações da inicial da ação.

A contestação à reconvenção foi instruída com documentos (fls. 1.259/1.256).

Houve réplica à contestação da reconvenção (fls. 1.269/1.278).

As partes especificaram provas (fls. 1.293 e 1.294/1.298), com a apresentação de novos documentos (fls. 1.299/1.319).

Foi acolhida a impugnação ao valor da reconvenção (fls. 1.320/1.321), sobrevivendo a regularização do recolhimento das custas (fls. 1.325 e 1.326/1.327).

O feito foi saneado (fls. 1.328/1.333).

Foi realizada audiência de instrução (fls. 1.371/1.372).

As partes se manifestaram em alegações finais (fls. 1.376/1.421 e 1.423/1.432).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Fundamentação

Por determinação do art. 2º da 8.955/94 (aplicável aos contratos celebrados entre as partes), "Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício".

Ademais, acerca das obrigações essenciais vinculadas ao contrato de franquia, ensina Carlos D. A. Braga que "considerando os elementos essenciais do conceito de franquia empresarial (...) podemos identificar algumas obrigações características", sendo que "[a]s obrigações do franqueado consistem basicamente no seguinte: (i) realizar o pagamento da contraprestação devida em razão da licença de uso de marca e da prestação de serviços de assessoria técnica empresarial, normalmente dividida em uma taxa inicial (também chamada de taxa de franquia) e em pagamentos mensais calculados com base em um percentual sobre o faturamento do franqueado (royalties); (ii) oferecer aos consumidores apenas produtos ou serviços sob a marca licenciada pelo franqueador, por ele fabricados ou por quem ele indicar; (iii) observar estritamente as instruções de comercialização dos produtos e serviços estabelecidas pelo franqueador" e que "[a]s obrigações do franqueador, por sua vez, são: (i) conceder ao franqueado o direito de uso de sua marca; (ii) prestar os serviços de assessoria técnica de organização empresarial" (in Tratado de Direito Comercial, volume 6: estabelecimento empresarial, propriedade industrial e direito da concorrência. Fábio Ulhoa Coelho (coord.). São Paulo: Saraiva, 2015. pp. 181).

No caso, foi documentalmente provado que as sócias da ré demonstraram interesse na franquia comercializada pela autora, razão pela qual foram prestadas informações e houve discussão sobre cláusulas contratuais, culminando no acerto entre as partes (fls. 39/41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/48, 49/51 e 52/55).

Como consequência, no dia 27/07/2015 as partes celebraram contrato de franquia para operação de unidade da rede de prestação de serviços de limpeza doméstica "House Maid", localizada no bairro da Vila Romana (fls. 56/79).

Em 01/04/2017 as partes celebraram um segundo contrato de franquia em razão da aquisição, pelas rés-reconvintes, da unidade "House Maid" situada no bairro de Perdizes (fls. 80/103).

Outrossim, em 21/08/2018 a VP LIMPEZA enviou notificação extrajudicial denunciando os contratos, alegando o descumprimento de deveres legais e de obrigações contratuais pela franqueadora (fls. 104/110).

Diante da impossibilidade de composição, a notificação foi confirmada por e-mail (fls. 119/122).

Pelo que se extrai da referida notificação, os motivos para a rescisão do contrato seriam: (i) a não entrega da COF; (ii) o fato do contrato ser leonino; (iii) e o fato de que "Desde o início da franquia, a Notificada deixou de dar suporte à Notificante, a qual sempre precisou recorrer de recursos próprios, ou resolver de forma independente os diversos problemas que vinham ocorrendo com material, uniforme, transporte, software, site, treinamento e qualificação do pessoal".

Em relação à alegação genérica de nulidade do contrato, por ser leonino, cumpre observar que os contratos pactuados pelas partes têm natureza empresarial, presumindo-se, portanto, que são qualificadas e habituadas com os negócios mercantis pactuados.

Como ensina Paula Forgioni, o funcionamento do mercado exige que os pactos sejam respeitados, de forma que "A força obrigatória dos contratos viabiliza a existência do mercado, coibindo o oportunismo indesejável das empresas" (in Contratos Empresariais. Teoria e Aplicação, 3ª ed., pp. 109/112, São Paulo, RT, 2018).

Ainda sobre o pacta sunt servanda, a Professora aponta que "Se lhes fosse permitido, os agentes econômicos valer-se-iam dos contratos para vincular apenas seus parceiros comerciais, e nunca a si próprios. No momento inicial, as partes creem que o negócio ser-lhes-á vantajoso; todavia, com o passar do tempo, é possível que o vínculo deixe de interessar a uma delas. Nasce anseio de se livrar da amarra contratual para seguir outro caminho. Partindo dessa premissa, compreende-se a importância sistêmica da força vinculante dos contratos; na sua ausência, seria impossível a coibição do descumprimento da palavra empenhada e o desestímulo de comportamento oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit - grifado).

Desta forma, os contratos são inevitavelmente válidos, salientando que não foi apontada eventual motivo concreto para justificar conclusão contrária.

No mais, em relação à alegação de que a circular de oferta de franquia não foi entregue com a antecedência legalmente exigida, a questão deverá ser analisada à luz do enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, verbis:

"A inobservância da formalidade prevista no art. 4 da Lei nº 8.955/94 pode acarretar a anulação do contrato de franquia, desde que tenha sido requerida em prazo razoável e que haja comprovação do efetivo prejuízo".

Independentemente da COF ter ou não sido entregue com a antecedência prevista no art. 4º da Lei n. 8.955/94, não há prova do efetivo prejuízo.

Pelo contrário, como já apontado, as partes efetivamente discutiram de forma prévia os termos do negócio e do instrumento (fls. 39/41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/48, 49/51 e 52/55), tendo celebrado o primeiro contrato em julho de 2015 (fls. 56/79), o que foi seguido pela celebração de um novo contrato em abril de 2017 (fls. 80/103).

Assim, a notificação extrajudicial foi enviada mais de três anos após a celebração do primeiro contrato (fls. 104/110), possibilitando a presunção de que eventual atraso ou ausência da entrega da COF não comprometeu a opção pela contratação da franquia, assim como o desempenho da atividade.

E a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual prejuízo, tal como apontado pelo enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado à alegação de que, desde o início da franquia, a franqueadora deixou de dar suporte à franqueada, "a qual sempre precisou recorrer de recursos próprios, ou resolver de forma independente os diversos problemas que vinham ocorrendo com material, uniforme, transporte, software, site, treinamento e qualificação do pessoal".

Ora, não há prova nos autos no sentido de que a autora tenha deixado de atender às solicitações da ré, sendo que os documentos de fls. 123/576 indicam no sentido diverso.

Não é razoável imaginar que a franqueada, sem reclamar formalmente, tenha convivido com sensível falta de suporte e a existência de graves problemas com material, uniforme, transporte, software, site, treinamento e qualificação do pessoal.

Considere-se, ainda, que tal situação perdurou por mais de três anos, tendo contratado nova unidade franqueada após dois anos de relacionamento.

Neste ponto, é importante observar que a prova meramente oral é insuficiente para a demonstração da falha na prestação de assessoria pela autora, eis que no caso está desprovida de qualquer amparo em documentos.

Ora, como já mencionado, não é crível que falhas sensíveis na transferência de know how e no assessoramento não tenham registro, sendo que as declarações da franqueada e de outros franqueados igualmente insatisfeitos, sejam considerados suficientes, após a caracterização do litígio.

Portanto, não foi demonstrada a existência de justa causa para a rescisão do contrato de franquia, razão pela qual a notificação extrajudicial de fls. 104/110 não produziu os efeitos pretendidos pela ré.

No mais, a prova oral demonstrou que a franqueadora estava autorizada a utilizar a marca "House Maid" no Brasil, que forma que tal argumento não pode ser utilizado para justificar a pretensão de rescisão dos contratos de franquia.

Por outro lado, os contratos contém obrigação de não concorrência pelo prazo de um ano após o término do contrato (cláusula 14.3 - fls. 75/76 e 99/100).

E não se vislumbra ilegalidade na obrigação de não concorrência, tal como contratada pelas partes.

Em que pese a livre iniciativa conste expressamente dos arts. 1º, IV, e 170, caput e IV, da CF, as partes são maiores e capazes e os negócios jurídicos versaram sobre direitos patrimoniais disponíveis, o que garante ampla liberdade para que as cláusulas sejam estabelecidas de acordo com a melhor conveniência das partes.

Mais ainda, como já mencionado, tratando-se de contrato empresarial, há presunção de que as partes são habituadas aos negócios que participam, tendo tomado as cautelas necessárias para a exata compreensão das obrigações assumidas, assim como das consequências.

Por tais razões, é inevitável reconhecer a incidência mais acentuada da autonomia privada e do pacta sunt servanda.

Em relação à obrigação de não concorrência, para Fábio Ulhoa Coelho, as limitações contratuais da concorrência são válidas se não a eliminarem por completo, por aplicação dos critérios materiais, temporais e espaciais:

"As cláusulas contratuais de disciplina da concorrência podem ou não ser válidas, de acordo com uma série de fatores, a serem especificamente analisados. Para a

análise, o critério mais relevante é o da preservação do livre mercado. Ou seja, as partes podem disciplinar o exercício da concorrência entre elas, desde que não a eliminem por completo. Em outros termos, a validade da disciplina contratual da concorrência depende da preservação de margem para a competição (ainda que futura) entre os contratantes; ou seja, da definição de limites materiais, temporais e espaciais. Em concreto, a vedação não pode dizer respeito a todas as atividades econômicas, nem deixar de possuir delimitações no tempo ou no espaço.

Em relação aos limites materiais, observa-se que a cláusula disciplinando a concorrência é inválida, se impede o contratante de explorar qualquer atividade econômica. A restrição deve necessariamente se circunscrever a determinados ramos de comércio, indústria ou serviços. Para as demais atividades, as partes ficam livres de qualquer obrigação (de não fazer). A propósito da restrição material, deve-se também considerar inválida a cláusula que impeça o contratante, pessoa física, de exercer a sua profissão. Por exemplo, o sócio que se desliga de sociedade de engenheiros pode, no instrumento de cessão de cotas, ficar impedido de competir com a sociedade, desde que os termos contratados não alcancem todas as atividades de engenharia para as quais o retirante se encontra profissionalmente habilitado ou preparado.

Também é inválida a cláusula que vede a concorrência para sempre ou em qualquer lugar. Limites temporais ou espaciais são exigidos, para que a restrição contratada não importe eliminação total da concorrência. Trata-se, aqui, de uma alternativa inclusiva; quer dizer, o contrato pode prever limite no tempo e no espaço, ou só num deles. A restrição contratual limitada apenas geograficamente se considera feita para sempre, enquanto a limitada apenas no tempo alcança todos os mercados (Ripert-Roblot, 1947:350). A invalidade existe quando não há simultaneamente limite temporal e espacial. É igualmente inválida a cláusula de não concorrência que estabelece prazo demasiado longo, ou defina limites espaciais exagerados, que ultrapassem o potencial de conquista de mercado que as partes possuem. Desse modo, é nula a cláusula de não estabelecimento que o empreendedor de shopping center, para evitar a concorrência autofágica, contrata com os lojistas, quando os limites territoriais nela referidos extrapolam os do mercado sobre o qual pode exercer atração" (in Curso de Direito Comercial, v. 1, cap. 7, São Paulo, RT, 2018 - grifado).

No caso, não se vislumbra qualquer nulidade na pactuação da obrigação de não concorrência, sendo que a melhor aplicação da boa-fé objetiva é exatamente no sentido da manutenção das obrigações validamente assumidas.

Suas consequências, por mais que eventualmente significativas, estão abrangidas no âmbito das justas expectativas.

Nesse sentido, os documentos de fls. 577/584 e as imagens de fls. 18/22 demonstram que a ré e suas sócias passaram a desenvolver atividade concorrente, com o nome "Ela Ajuda", o que, aliás, não foi impugnado.

E como já apontado, a notificação extratutudicial enviada pela ré não produziu os efeitos pretendidos, eis que não há justa causa para a rescisão do contrato.

Portanto, restou demonstrada a efetiva concorrência realizada pela ré, em evidente contraposição ao que foi contratualmente estabelecido pelas partes.

Assim, há que se reconhecer que a ré deu causa à rescisão dos contratos de franquia, por terem encerrado as atividades sem a observância das regras estabelecidas pelas partes, passando imediatamente a desenvolver atividade concorrente, o que era expressamente proibido (cláusula 14.3 - fls. 75/76 e 99/100).

Como consequência, a ré deu causa à incidência da cláusula penal prevista na cláusula 16.3 dos contratos de franquia (fls. 77 e 101).

Assim, a ré deverá pagar R\$ 120.000,00, em relação a cada um dos contratos.

Além disso, ao realizar concorrência proibida, a ré deu causa à incidência da multa prevista na cláusula 14.5 dos contratos de franquia (fls. 76 e 100).

Assim, a ré deverá pagar R\$ 250.000,00, em relação a cada um dos contratos.

Por fim, uma vez que as partes estabeleceram a consequência pecuniária para o descumprimento da obrigação de não concorrência (cláusula 14.5 - fls. 76 e 100), não é possível o acolhimento cumulativo da pretensão de imposição da obrigação de não concorrência, pelo prazo de um ano.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo o pedido reconvenicional improcedente e julgo o pedido principal parcialmente procedente, para:

determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC;

condenar a ré ao pagamento de R\$ 740.000,00, acrescido de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data da assinatura do contrato de franquia, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira citação;

determinar que a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético (art. 509, § 2º, do CPC), que deverá ser elaborado diretamente pelo credor;

com fundamento no - art. 85, § 2º, do CPC, condenar a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pela autora, fixados em 10% do valor da condenação (ação principal) e em 10% do valor atribuído à reconvenção. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 19 de abril de 2022.

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita